

1501025-93.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... o local dos fatos ser conhecido como ponto de tráfico e, ainda, o depoimento das testemunhas, levam à certeza de que o réu trazia drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501025-93.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501025-93.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119264/2020 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 11413464 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 1383/20/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2119264 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

RYAN FELIPE SANTANA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

RYAN FELIPE SANTANA DOS SANTOS qualificado nos autos esta sendo processado como incurso no 33 caput c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, porque segundo narra a denúncia de fls. 01/02, no dia 14 de maio de 2020, por volta de 11h32, em via pública, nas imediações de estabelecimento de ensino, à Rua Osório Duque Estrada, altura do nº 93, Jardim Planalto do Belém, Francisco Morato/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar trazia consigo: I) 42 (quarenta e duas) porções da droga conhecida como crack, acondicionadas em invólucros plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 13g (treze gramas); II) 28 (vinte e oito) porções da droga conhecida como maconha, acondicionadas em invólucros plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 19g (dezenove gramas) e; III) 21 (vinte e uma) porções da droga conhecida como cocaína,

acondicionada em um saco plástico, com massa bruta total de aproximadamente 19g (dezenove gramas).

Às fls. 48/49 concedeu ao acusado a liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão de fls. 83 adotou o rito ordinário e determinou a citação do réu.

O réu foi citado (fls. 99) e apresentou defesa prévia às fls. 103/106).

A decisão de fls. 109/110 ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e debates por videoconferência em razão da pandemia da Covid-19.

Em audiência de instrução e julgamento o réu foi interrogado, bem como ouvidas duas testemunhas de acusação.

O Ministério Público, em alegações finais pediu a procedência parcial. Afirmar que não demonstrado que a comercialização se destinasse ao colégio. Afirmar que também possível a consideração do tráfico privilegiado. Cabível a substituição da pena por restritiva de direitos.

A Defesa de apresentou alegações finais concordando com os fundamentos do Ministério Público.

Documentos juntados: auto de exibição/apreensão da droga e dinheiro (fls. 12); laudo de constatação da droga (fls. 14/19); croqui do local dos fatos (fls. 26); laudo pericial químico toxicológico (fls. 77/82); guia de depósito judicial (fls. 94); folha de antecedentes (fls. 95/97).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo, bem assim, laudo de constatação preliminar da droga e laudo de exame de substâncias psicoativas, auto de apreensão da droga/dinheiro e guia de depósito de dinheiro apreendido.

A testemunha DEBORA MARIA GONÇALVES foi ouvida na fase de inquérito (fls. 06) e afirmou: "Que estava na companhia de seu parceiro de viatura Sd. J.Silva, quando em patrulhamento pelo local dos fatos, surpreendeu o indivíduo Ryan e m atitude suspeita. Ao tentar realizar abordagem o mesmo empreendeu fuga sendo abordado logo adiante em poder de uma sacola. Em revista pessoal foi encontrado R\$ 85,00 em seu bolso e no interior da sacola fora localizado 42 unidade de crack, 28 unidades de maconha e 21 unidades de cocaína. Indagado disse que a droga não era sua e que estava segurando tal sacola a pedido de um conhecido de nome Thiago não sabendo declinar onde possa ser localizado. Esclarece que o indiciado fora surpreendido há aproximadamente setenta metros da Escola EMEI Fernando Pessoa." Em juízo afirmou: que o local é ponto forte de venda de entorpecente; que visualizado o réu ele deu fuga; que na abordagem ele estava com sacola (cocaína, crack e maconha); que havia R\$ 85,00 em dinheiro com ele; que o réu afirmou que a sacola não era dele mas estava segurando para Thiago; que não se recorda do réu; que não se recorda se havia outros civis no local; que o local é próximo à escola Fernando Pessoa; que a escola Afonso Moreno é mais distante do local dos fatos; que de onde o réu estava dava cerca de 70m da escola municipal; que a rua é descendo a escola que fica na Guimarães Rosa, ou seja, transversal;

A testemunha JEFFERSON JOSE DA SILVA também ouvida na fase policial (fls. 07) afirmou: "Que estava na companhia de seu parceira Sd. Debora realizava patrulhamento quando surpreendeu o indivíduo Ryan em atitude suspeita. Ao tentar realizar abordagem o mesmo empreendeu fuga sendo abordado logo adiante em poder de uma sacola plastica de supermercado. Em revista pessoal foi encontrado R\$ 85,00 em seu bolso e no interior da sacola fora localizado 42 unidade de crack, 28 unidades de maconha e 21 unidades de cocaína. Indagado disse que a droga não era sua e que estava segurando tal sacola a pedido de um conhecido de nome Thiago não sabendo onde o mesmo possa ser achado. Esclarece que o indiciado fora surpreendido há aproximadamente setenta metros da Escola EMEI Fernando Pessoa." Em juízo afirmou: que estavam em patrulhamento e viram o réu que tentou empreender fuga, tendo sido abordado; que em seu bolso havia R\$ 85,00 e na sacola que ele segurava havia entorpecentes; que o réu afirmou que segurava a sacola para outro indivíduo que o depoente não se recorda o nome; que segundo o réu o indivíduo teria passado pelo

local, pedido para ele segurar a sacola e ele segurou; que o local é via comum, passando dentro do bairro Santo Antonio e a viatura estava em patrulhamento ordinário; que o réu estava sozinho no momento em que foi visualizado; que não havia outros civis no local; que a sacola e local motivaram a abordagem; O réu RYAN FELIPE SANTANA DOS SANTOS foi interrogado na fase de inquérito (fls. 08), afirmando: "Que é usuário de maconha e estava no local para comprar entorpecente, quando a pessoa de Tiago, seu conhecido, pediu para o segurasse uma sacola plástica de supermercado com drogas. Ao ver a viatura da Polícia Militar saiu correndo com tal sacola sendo abordado há alguns metros adiante. Esclarece que foi abordado sendo encontrado o dinheiro que Tiago havia deixado consigo bem como as drogas no interior da sacola. Declina por fim que não trabalha, não tem filhos, mora com os pais e não tem conhecimento de maiores informações de onde Tiago possa ser localizado." Em juízo afirmou: que no dia dos fatos tinha ido comprar a droga; que estava muito precisando de dinheiro e o Tiago, desconhecido, falou que tinha horário para passar, dando a sacola com as drogas, pagando R\$ 85,00 para que o réu segurasse a droga até que ele retornasse para assumir o turno. Observo que as testemunhas de acusação apresentaram um depoimento coeso na fase policial, o qual foi reafirmado judicialmente e que encontra respaldo nas demais provas amealhadas aos autos, com presunção de idoneidade. Nesse sentido:

"Depoimentos de policiais. Presunção de idoneidade. São idôneos os depoimentos de policiais civil e militares, prestados na polícia e em Juízo, de forma coerente e em harmonia com outros elementos probatórios existentes nos autos, podendo embasar decreto condenatório" (RJTJERGS 182/132). É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que os acusados e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade: "O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586); "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189); "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275); "Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" . (TJMG, RT 604/407). Como visto, os depoimentos das testemunhas são claros quanto à efetiva participação do réu no crime de tráfico e nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos

policiais, lembrando que pequenas divergências entre as declarações prestadas, sequer existentes na hipótese, não bastam, por si só, para infirmá-las.

Além disso, não demonstrou a Defesa, como seria de rigor, eventual motivo que teriam os policiais civis para mentir em juízo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (artigo 156, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

"PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

Por outro lado, assevero não ser crível a versão do réu de que saiu de casa para comprar uma porção de maconha e no momento da abordagem apenas segurava a sacola contendo drogas para um indivíduo que identificou como Thiago (então traficante), afirmando que "Thiago, falou que tinha horário para passar, dando a sacola com as drogas, pagando R\$ 85,00 para que o réu segurasse a droga até que ele retornasse para assumir o turno". De qualquer modo, ainda que aceita a versão do réu, ainda estaríamos falando da sua atuação no tráfico de entorpecentes.

Destaca-se, quando ao ônus de prova, que cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto.

Neste caso, existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado.

Neste sentido a defesa não supriu a falta dos elementos indispensáveis para a realização da prova, visto que não indicou testemunhas, nomes, endereços ou quaisquer provas ou indícios que roborassem o alegado.

Assim a versão apresentada pelo réu apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se.

Portanto, demonstrado que o réu trazia a droga, o seu destino tem que ser analisado pelos demais elementos que cercam a questão.

No caso dos autos, a quantidade e variedade de droga apreendida (maconha, cocaína, crack), a forma como estava dividida e embalada para pronta distribuição, o local dos fatos ser conhecido como ponto de tráfico e, ainda, o depoimento das testemunhas, levam à certeza de que o réu trazia drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em "possuir", "guardar" e "trazer consigo" a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito. A propósito: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542). Desse modo, bem demonstrada se encontra a responsabilidade penal do réu pelo delito apontado na inicial, sendo de rigor a sua condenação. Em suma, demonstrado que o

réu trazia consigo I) 42 (quarenta e duas) porções da droga conhecida como crack, acondicionadas em invólucros plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 13g (treze gramas); II) 28 (vinte e oito) porções da droga conhecida como maconha, acondicionadas em invólucros plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 19g (dezenove gramas) e; III) 21 (vinte e uma) porções da droga conhecida como cocaína, acondicionada em um saco plástico, com massa bruta total de aproximadamente 19g (dezenove gramas) tudo conforme depoimentos prestados em sede policial, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória de substância entorpecente, croqui do local dos fatos e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos. , o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de comercialização.

Passo, pois, à dosagem da pena.

1.A) Pena-base: 5 anos e 10 meses de reclusão e, 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza/variedade da droga, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso dos autos, tratando-se de tráfico de maconha, cocaína e crack, entendo por exasperar a pena-base em 1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu não é portador de maus antecedentes, conforme certificam os documentos de fls. 95/97 e 94.

Em se tratando de delito submetido a Lei de Drogas, o conteúdo do artigo 42 do diploma dispõe que: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes do STF: vg. HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki.

Anoto que: a Cocaína é substância entorpecente, altamente viciante que afeta o sistema neurológico e imunológico de forma irreversível, e, além de transformações internas, o uso constante causa uma degradação física evidente; no que se refere ao crack - especialistas classificam como a terceira droga mais prejudicial ao usuário, apesar de ser derivado da cocaína, o crack, pelo fato de ser consumido por meio de fumo tem seus efeitos ainda mais potentes e duram períodos mais curtos, o que gera o consumo de maiores quantidades; a heroína - é considerada como uma das drogas mais viciantes e perigosas do mundo pela OMS (Organização Mundial da Saúde) isso pelo seu alto nível de vício e dependência, ademais, diminui a frequência cardíaca o que caracteriza grande riscos de o consumidor sofrer uma overdose. Quanto a fração a ser aumentada, é sabido que não há previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto. Desta forma: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Destaco que, respeitado posicionamento diverso, entendo que a natureza da droga deve ser considerada nessa fase inicial, autorizando-se que o réu seja beneficiado com eventual atenuante ou causa de diminuição de pena, caso incorra na hipótese. Assim, estará sendo alcançada uma justa individualização da pena, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Por outro lado, filio-me à orientação de que a quantidade de droga nos dá parâmetro para análise da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, salvo em casos em que estiver presente os maus antecedentes e/ou a reincidência que já revela a trajetória criminosa do réu.

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o delito foi cometido durante a pandemia da Covid-19, razão pela qual, com fundamento no artigo 61, II, "j" aumento a pena em mais 1/6, resultando em 7 anos de reclusão e 700 dias multa.

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do

crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4a Câmara Criminal, j. 09/03/2021).

C) Causas de aumento e de diminuição: Já com relação a causa especial de aumento de pena referente à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, entendo que não está presente, pois a razão de ser da norma está ligada a expor o maior número de pessoas à ação do traficante, mas no caso dos autos, os fatos ocorreram durante o período de férias escolares.

Não obstante o croqui apresentado às fls. 26, verifico que o crime, como dito anteriormente, foi cometido durante a pandemia da Covid-19, ocasião em que as aulas presenciais estavam suspensas, deixando assim de evidenciar que o réu efetivamente se beneficiaria dessa proximidade para a prática do delito e, em outra via, exporia o maior número de pessoas ao risco da atividade do tráfico, já que o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido que a causa de aumento deve incidir sempre que o tráfico seja praticado em locais em que há maior facilidade de difusão do vício diante da maior concentração de pessoas. Assim sendo, o fato de o crime ter ocorrido no período de férias, não há como se presumir que naquela data havia aglomeração de pessoas esperada durante o período letivo.

Nesta esteira, e diante da ausência de provas de que o agente tenha se valido dessa localização, supostamente privilegiada, para angariar nova "clientela", de rigor o alijamento da majorante. Neste sentido encontra-se o entendimento do Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo:

MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga maconha e cocaína. AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância tipo congruente. CAUSA DE AUMENTO proximidade de estabelecimento de ensino afastamento período de férias escolares. PENA afastado o redutor, mantida no mais a reprimenda. REGIME inicial fechado manutenção. Apelação nº 0001689-65.2015.8.26.0160, da Comarca de Descalvado- LAURO MENS DE MELLO

Tráfico de entorpecentes Prisão em flagrante na posse de várias porções de cocaína Denúncia anônima apontando o acusado como responsável pelo tráfico Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos Ausência de motivos para duvidar dessas palavras Crime permanente - Desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06 Impossibilidade Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes Proximidade de escola Fato ocorrido no mês de janeiro Falta de comprovação de que o tráfico se destinava ao público daquele julgar Qualificadora Não caracterização Réu reincidente Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos Impossibilidade

Recurso parcialmente provido. Apelação nº 000003298.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu - Alexandre Almeida

Por fim, o disposto no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas dispõe que, para que incida a causa de diminuição da pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

No caso em apreço, o réu preenche os requisitos legais para a configuração de tráfico privilegiado.

O diploma legal prevê que, nesses casos, a pena poderá ser reduzida de 1/6 a 2/3. Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum dessa redução, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, podem ser utilizadas para definir tal índice ou, até mesmo, para afastar a incidência da benesse quando evidenciarem dedicação à atividade criminosa de comércio ilícito de entorpecentes, neste sentido: AgRg no REsp 1.644.417/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no AREsp 857.658/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016. Ressalto o entendimento do Ministro Gilmar Mendes em julgamento do HC 99.440/SP mencionado pelo Ministro Joaquim Barbosa no HC 165.782/MG: "O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto".

E, neste sentido, julgado do STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado (HC 100.755/AC, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma)

Analisando as peculiaridades presentes no caso, principalmente a quantidade de droga, entendo ser proporcional a diminuição da pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, a qual torno definitiva.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo que na espécie é de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

D) LIBERDADE: O acusado faz jus ao apelo em liberdade, pois respondeu em liberdade ao processo, não havendo fatos supervenientes a indicarem a necessidade da custódia cautelar no presente momento.

E) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: Nos termos do artigo 33, do Código Penal fixo o regime SEMI-ABERTO para início de cumprimento da reprimenda, considerando as circunstâncias anotadas na primeira fase de dosimetria da pena. Nesse sentido: "O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga." (STJ, HC 314102/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 12/04/2016, DJE 26/04/2016).

F) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Não estão presentes os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

G) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não estão presentes os requisitos do artigo 77, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu RYAN

FELIPE SANTANA DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. § 4º do artigo 33 da mesma norma, fixando-a em reclusão de 5 e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida nos termos da fundamentação.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, ficando, nos termos do artigo 63 da Lei 11.340 decretada a perda da importância de R\$ 85,00 em favor da União, que deverá ser revertida diretamente ao Funad.

Libere-se certidão de honorários a favor da Defesa, na hipótese de nomeação pelo Convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil, no valor integral de tabela ou no equivalente a 70% (setenta por cento), se houver recurso.

Condeno, outrossim, o acusado ao pagamento de taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, "a", da Lei nº 11.608/03, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C. Sentença registrada eletronicamente.
Francisco Morato, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA